

1500201-54.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... conhecer Rafael. Já teve envolvimento com o tráfico de drogas enquanto era adolescente. Já foi internado na Fundação CASA por duas vezes, por roubo e tráfico de maconha. Quem o prendeu por tráfico quando adolescente foi o policial José Carlos. Não tinha a chave da residência porque estava somente ficando lá depois de ter brigado com sua mãe.

Eis a prova oral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, nº 60 - Vila São Paulo - Araçatuba/SP - CEP 16015-925

1500201-54.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500201-54.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1859/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

MATEUS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, porque, segundo a denúncia, no dia 05/02/2020, por volta de 23h10, na residência situada na rua Amadeu Vuolo nº 1337, bairro Verde Parque, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 36,41 g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, droga essa capaz de causar dependência, consoante demonstra o laudo de exame químico-toxicológico de fls.70/72, bem como porque, no mesmo local e ocasião,

possuía arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante em 05/02/2020 (fl. 12). Pela r. decisão de fls. 53/54 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O mandado de prisão foi cumprido em 06/02/2020 (fls. 57/58). Pela r. decisão de fl. 107, a prisão preventiva foi revogada, a pedido do representante do Ministério Público (fls. 105/106), sendo concedida ao réu a liberdade provisória. O alvará de soltura foi cumprido em 08/04/2020 (fls. 126/128).

O réu foi notificado à fl. 189 e apresentou defesa prévia às fls. 192/197. Não estando presente quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, a denúncia foi recebida em 23/07/2021 (fls. 203/205).

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 224/237).

Em alegações finais orais (fl. 225), o representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação, com a condenação do réu nos moldes da denúncia, vez que comprovadas a materialidade e autoria dos crimes. Requer sejam consideradas na dosimetria da pena a condenação anterior pela prática de tráfico, bem como as passagens do réu pela Vara da Infância.

Em alegações finais (fls. 225/228), a defesa do réu requereu o reconhecimento da atenuante decorrente da confissão espontânea para o delito de posse irregular de arma de fogo; o reconhecimento da atenuante decorrente da menoridade relativa; a absolvição do réu em relação ao delito de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e a imposição de regime inicial semiaberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Sentencio o presente feito, face ao afastamento do MM. Juiz que encerrou a instrução probatória.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 12), boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), laudo de constatação prévia de entorpecente (fl. 28), laudo definitivo de constatação de entorpecentes (fls. 70/72), laudo de exame em arma de fogo (fls. 117/122), relatório policial (fls. 80/81), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

O policial militar Télcio Juliano Gil, ouvido em juízo (fls. 229/230), em consonância com o depoimento prestado na fase policial (fls. 13/14), relatou que estavam em patrulhamento pela Rua Dois de Dezembro, momento em que avistaram um veículo VW/Gol, cujo passageiro (réu) apresentou movimentação estranha, tentando se abaixar, razão pela qual decidiram abordá-los. Nada de ilícito foi localizado com os ocupantes. O motorista foi liberado por não haver contra si qualquer mandado pendente e pelo fato de ter afirmado na ocasião que estava realizando serviço de transporte pelo aplicativo Uber. Os policiais já haviam recebido informação de que, há cerca de 10 dias, certo indivíduo havia matado o sogro. Receberam foto deste indivíduo e por isso o reconheceram como sendo o passageiro do carro, que tentara se esconder. Indagaram o réu a respeito do homicídio, tendo ele confirmado o fato,

informando que o sogro havia tentado lhe matar, atropelando-o. Disse que residia no bairro Verde Parque, na Rua Amadeu Vuolo, nº 1337, na companhia de um indivíduo chamado Rafael. Disse que a arma do crime estaria dentro do fogão da residência. Afirmou que na casa moravam apenas ele e Rafael. Confessou também aos policiais que seriam encontradas na residência entorpecentes, explicando que a venda de drogas seria uma forma de pagar o aluguel da residência e os honorários advocatícios, pois pretendia se entregar após a prática do homicídio. O depoente disse que diligenciaram até a residência informada pelo réu, a qual estava trancada e, por isso, tiveram que arrombá-la, vez que o réu informou não estar com as chaves. Lograram êxito em encontrar a arma de fogo com 6 munições intactas, além de 11 munições também intactas ao lado. Durante a busca, também localizaram, no quarto, 37 pinos de cocaína, além de R\$ 180,00 em notas de 20, 10 e 50 reais. Rafael não se encontrava no local, mas sua mãe foi à residência crendo que o filho tinha sido preso. A mãe de Rafael confirmou aos policiais que ele e Mateus residiam naquela casa. O depoente conhecia o réu de abordagens anteriores. Os outros policiais sabiam do envolvimento dele com o tráfico, conhecendo-o pela alcunha de "Sueg". Fora a palavra do réu, não se recorda se havia outros indícios dele ali residir. Não se recorda do réu dizer residir em outro local, mas os policiais sabiam que ele nem sempre ali residiu, acreditando que o tenha feito somente a partir da prática do homicídio.

O policial militar José Carlos da Silva, ouvido em juízo (fls. 231/232), em consonância com o depoimento prestado na fase policial (fls. 15/16), relatou que estavam em patrulhamento pela Rua Dois de dezembro, momento em que viram um veículo Gol prata, cujo passageiro apresentou movimentação estranha (tentando se esconder), razão pela qual decidiram abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado com nenhum dos ocupantes do veículo. Porém, o passageiro, ora réu, foi reconhecido pelos policiais como a pessoa que dias antes havia matado o sogro. Mateus já era conhecido nos meios policiais. Indagaram o réu a respeito do homicídio ocorrido no bairro Águas Claras, respondendo ele ter matado o sogro, pois este havia tentado lhe matar em ocasião anterior, jogando o carro contra si. O réu disse que residia no Bairro Águas Claras na companhia de Rafael e que a arma estaria escondida dentro do forno da residência. Além disso, afirmou aos policiais que havia drogas na casa, mas não precisou o local. A casa estava trancada e, por isso, tiveram que arrombá-la. Rafael não se encontrava no local. Lograram êxito em encontrar a arma de fogo, calibre 32, municiada com 6 cartuchos intactos e mais 11 munições reserva. Durante a busca, seu parceiro Télcio localizou, no quarto, 27 pinos contendo cocaína e R\$ 180,00 em notas diversas. O réu disse que os entorpecentes localizados na residência seriam vendidos por ele e por Rafael como uma forma de pagar honorários advocatícios, vez que pretendia se entregar pela prática do homicídio. A mãe de Rafael, Adriana, compareceu ao local, perguntando se o filho havia sido preso. Adriana não soube informar o paradeiro do filho. Conhecia o réu, pois procedeu em data anterior à sua condução à delegacia pelo crime de tráfico de drogas. Não sabia onde o réu estava morando, pois havia informações de que estava foragido. Na casa havia dois quartos. Não sabe dizer a quem pertencia o quarto em que as drogas foram encontradas. Só sabe que era o quarto em que havia um guarda-roupa. Reafirma que o réu lhe informou que estava vendendo as drogas para custear o pagamento de um advogado, pois pretendia se apresentar à autoridade policial. Sabe que o réu morava anteriormente com sua mãe no bairro Castelo Branco, mais conhecido como Seiscentas Casas, pois este era seu endereço quando o conduziu em ocorrência anterior de tráfico de drogas. O réu não tinha as chaves do imóvel e por isso tiveram que arrombá-la. O réu disse que Rafael estaria na casa e abriria a porta para ele quando lá chegassem.

O policial civil Elias Pichirillo Junior, ouvido em juízo (fls. 233/234), disse que teve conhecimento dos fatos apurados nestes autos somente após a sua ocorrência. Recebeu um pedido de diligências, feito pelo Ministério Público, para comparecer a uma residência localizada na Rua Amadeu Vuolo, nº 1.337, para tentar localizar Adriana Vargas, genitora de Rafael Vargas. Contudo, em todas as oportunidades que

lá compareceu encontrou a casa fechada. Questionaram os vizinhos, mas estes disseram que a residência estava há alguns dias fechada e que não havia nenhum movimento de pessoas por ali. Não teve contato com nenhum dos envolvidos. Já abordou o réu em outra oportunidade, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 235/237), o réu Mateus Henrique Pereira de Oliveira disse ser conhecido pelo apelido de "Sueg" e já ter sido condenado por tráfico de drogas. Está preso por homicídio. Quando foi abordado, os policiais lhe perguntaram onde estaria a droga e o revólver. Respondeu que tinha um revólver na casa em que estava morando com Rafael, vez que saiu de casa porque brigou com sua mãe. Sabe que Rafael vendia drogas. O revólver era emprestado de um amigo de ambos, não sendo de propriedade nem dele nem de Rafael. Esse amigo lhe emprestou o revólver porque havia brigado e matado seu sogro. Relatou aos policiais que na residência poderia haver drogas, mas que não seriam suas, mas de Rafael. Quando o policial encontrou os entorpecentes disse a ele que deveria assumir a propriedade, vez que já havia sido preso por tráfico. Reafirma que a droga encontrada não era sua, mas do Rafael, que as comercializava na residência. Só estava naquela residência porque brigou com sua mãe, mas sempre residiu no bairro Primavera. Depois que cometeu o homicídio estava morando na casa de sua tia Simone, no bairro Seiscentas Casas. Não estava vendendo drogas para pagar advogado, vez que nem tem patrono constituído. A arma estava dentro do forno micro-ondas, tendo indicado o local para os policiais. O policial José Carlos que o prendeu no tráfico e neste processo sempre o ameaçava e dizia que iria prendê-lo com drogas "forjadas". Não conhece os outros dois policiais que depuseram. Afirmar ter mentido na delegacia sobre o fato de não conhecer Rafael. Já teve envolvimento com o tráfico de drogas enquanto era adolescente. Já foi internado na Fundação CASA por duas vezes, por roubo e tráfico de maconha. Quem o prendeu por tráfico quando adolescente foi o policial José Carlos. Não tinha a chave da residência porque estava somente ficando lá depois de ter brigado com sua mãe.

Eis a prova oral colhida.

Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003).

Encerrada a instrução processual, restou comprovado nos autos que o réu mantinha a posse irregular de uma arma de fogo de uso permitido.

As testemunhas, policiais militares, foram uníssonas ao informar que realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo, com dois ocupantes. Perceberam que o indivíduo que ocupava o banco do passageiro, assim que avistou a viatura, tentou se esconder, abaixando-se. Procedida à abordagem, os policiais reconheceram o passageiro como sendo o réu Mateus, havendo conhecimento de que ele havia cometido homicídio contra seu sogro há cerca de dez dias.

Conforme confirmado pelo próprio réu em juízo, os policiais lhe indagaram acerca da arma utilizada no crime, tendo ele afirmado que o objeto estava escondido numa residência localizada na Rua Amadeu Vuolo, nº 1.337, onde estaria morando juntamente com indivíduo chamado Rafael.

Em diligência ao local indicado pelo réu, os policiais lograram localizar, dentro de um forno, um revólver da marca Smith & Wesson, de calibre 32, numeração 480311, municiada com 6 (seis) cartuchos intactos. De igual modo, foram encontrados juntamente com o revólver mais 11 (onze) munições íntegras.

Quanto ao acusado, observa-se que confessou a prática do delito tanto na fase policial (fl. 17), quanto em juízo, afirmando ter guardado o revólver na residência referida.

Vale destacar que o teor do que foi confessado pelo réu está em consonância com as demais provas colhidas nos autos, notadamente a prova testemunhal e pericial de fls. 117/122. Ademais, a confissão do delito, de forma livre e espontânea, serve como importante elemento de convicção para demonstrar a autoria e amparar a condenação, quando encontrada sustentação nos demais elementos de convicção produzidos, como é o caso dos autos.

A prova pericial comprovou a aptidão da arma de fogo para a realização de disparos. Foi atestado pelo perito que os mecanismos do revólver calibre 32 LONG CTG, da marca Smith & Wesson, inscrição 480311, encontravam-se devidamente aptos para a realização de disparos, conforme testes efetuados (fl. 118).

Observa-se, ainda, que acompanhavam a arma 01 (um) cartucho da marca FMFLB, calibre nominal 32, dotado de projétil do tipo chumbo nu, ogival, com espoleta de cor prata, além de 16 (dezesseis) cartuchos, da marca Aguila, calibre nominal .32, da marca Smith & Wesson, dotados de projéteis do tipo chumbo nu, ogival, com espoletas de cor dourada (fl. 118), todos também aptos para a realização de disparos (fl. 119).

Assim, resta claro que o réu tinha a posse de arma de fogo de uso permitido no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual sua conduta enquadra-se no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

Importante ressaltar que o crime em foco é de mera conduta, ou seja, sua consumação se dá independentemente da arma de fogo estar municiada e da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo que a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo a conduta ilícita e plenamente dotada de potencial vulnerante, ressaltando-se que o acusado confessou ter utilizado a referida arma na prática de homicídio, em data anterior aos fatos aqui apurados.

Nesse sentido, é o posicionamento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5º, INC. I, DO CPP NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. [...]" (STJ, AgRg no AREsp 1729897/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Portanto, diante das provas colhidas nos autos, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, restou cabalmente comprovada, sendo a condenação medida de rigor.

Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Encerrada a instrução processual, restou comprovado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas comuns ouvidas em Juízo, bem como pelas

circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas.

As testemunhas policiais militares foram uníssonas ao confirmarem que, depois de realizada a abordagem do réu, conforme exposto acima, este confessou que estaria residindo na casa de seu amigo Rafael, onde seriam encontrados uma arma de fogo e entorpecentes.

Os policiais relataram que o réu confessou informalmente que estaria vendendo drogas na residência juntamente com Rafael, explicando que o numerário obtido com a venda seria empregado no pagamento do aluguel daquele imóvel e também utilizado para o pagamento de honorários advocatícios, porquanto pretendia se apresentar à autoridade policial após ter praticado um crime de homicídio.

De forma harmônica e concisa, os policiais militares informaram que o próprio réu lhes informou o endereço da residência, dizendo que Rafael estaria lá e franquearia a entrada. Ocorre que o imóvel se encontrava fechado, sendo necessário o arrombamento. Ressalto que estes fatos foram confirmados pelo próprio réu em juízo, tendo ele admitido que não detinha as chaves do imóvel porque apenas estava "ficando" na residência por algum tempo, depois de ter brigado com sua mãe e saído de casa.

Durante a diligência e buscas pelo local, os policiais disseram ter encontrado num dos quartos do imóvel 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, além de R\$ 180,00 em notas de 20, 10 e 50 reais.

Por essa razão, não há motivos para se desmerecer a palavra dos policiais militares, vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/26 e laudos periciais de fls. 28 e 70/72.

Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos são coincidentes entre si, com riqueza de detalhes, estando em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos na seara policial (fls. 13/16) o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição que se preste a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de querer indevidamente prejudicar o réu, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Com efeito, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Caracteriza-se, portanto, a prova produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Nesse sentido, a versão exculpatória apresentada pelo acusado, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, não merece credibilidade, porquanto inverossímil a alegação de que a droga pertencia somente ao indivíduo de nome Rafael.

Primeiramente porque os policiais foram uníssonos ao afirmar que o réu lhes confessou a prática do tráfico de drogas, dizendo atuar em conluio com Rafael e esclarecendo que pretendiam angariar dinheiro para pagamento do aluguel do imóvel e também para que Mateus arcasse com os custos da contratação de um advogado para defendê-lo no processo referente ao homicídio praticado.

Neste ponto, embora a defesa alegue o contrário, em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que o réu está realmente sendo assistido por advogado constituído nos autos do processo nº 1500544-17.2020.8.26.0032 (homicídio), em trâmite perante este juízo, o que corrobora o relato dos policiais militares.

Ademais, nota-se que o réu não arrolou nenhuma testemunha que pudesse imputar somente a Rafael a propriedade das drogas.

Por fim, não há qualquer indício nos autos no sentido de que os policiais militares imputaram ao réu a propriedade de drogas que sabiam não lhe pertencer, somente pelo fato de já ter sido condenado por tráfico de entorpecentes anteriormente.

Vale dizer, o próprio acusado reconheceu em juízo que sabia que o réu Rafael vendia drogas no imóvel. Além disso, afirmou ter informado aos policiais, antes da diligência, que na residência poderiam ser encontrados os entorpecentes.

Além disso, o próprio acusado afirmou ter sido condenado em primeira instância pela prática de tráfico de drogas, sendo réu confesso naqueles autos, bem como admitiu ter cumprido medida socioeducativa de internação pela mercancia ilícita de entorpecentes durante a adolescência.

De mais a mais, o modo como a droga estava acondicionada e a quantidade apreendida (36,41 gramas de cocaína, dividida em 37 pinos plásticos do tipo "eppendorf") deixa claro que se destinava ao tráfico.

Neste contexto, a narrativa do acusado de que não praticava o tráfico de drogas naquela residência não convence, tendo sido infirmada pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

Assim, as circunstâncias fáticas não deixam dúvidas acerca da prática delitiva, vez que, segundo afirmado pelos policiais, o réu confirmou a propriedade das drogas, esclarecendo, inclusive, os motivos pelos quais estava praticando o tráfico.

Além disso, foi encontrada na residência a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) em notas diversas, fato que, somado às demais circunstâncias, evidencia ainda mais a mercancia ilícita de drogas.

Consigno ser desnecessária a exigência da prova presencial da mercancia do entorpecente para consumir o crime de tráfico de drogas, posto que, sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova, como de fato se deu no presente caso.

Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o entorpecente.

A propósito, sobre o tema o E. TJ/SP já decidiu que: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a

ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

Também não é o caso de se aplicar ao réu a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, uma vez que foi condenado em primeira instância por tráfico ilícito de entorpecentes (autos nº 1500819-33.2019.8.26.0603, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Araçatuba - fl. 47). Ademais, embora tecnicamente primário, verifica-se que o réu praticou durante a adolescência ato infracional equiparado ao tráfico, sendo submetido à medida socioeducativa de internação nos autos do processo de apuração de ato infracional nº 0007558-97.2018.8.26.0032, que tramitou perante a 2ª Vara das Execuções Criminais e Anexo da infância e da Juventude desta comarca (fl. 49).

Sendo assim, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos e demais circunstâncias do delito, restou demonstrado que o acusado não se trata de traficante eventual, mas sim de pessoa que se dedicava habitualmente à atividade ilícita, indicando que agia de forma contínua, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido se posicionou a Terceira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. (...) Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (REsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017, g.n.).

E ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. In casu, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas



circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que o histórico infracional do recorrente, com registro de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, não deixa dúvida de sua notória progressão criminosa. Cumpre registrar, ainda, que com ele foram apreendidos 51,7 g de maconha, 21,8 g de cocaína e 7,7 g de crack. 4. Vale anotar que "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020). 5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1822052/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) g.n.

A lei é taxativa quanto aos pressupostos para a concessão das benesses, sendo tal rol cumulativo e, dentre eles, exige-se a primariedade e os bons antecedentes.

Quanto à quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) apreendida nos autos (fl. 69), verifica-se que o réu não demonstrou a origem lícita do dinheiro, tendo sido o numerário apreendido nas mesmas circunstâncias fáticas do entorpecente, o que demonstra sua relação com o comércio nefasto da droga.

Assim, a conduta do réu, consistente na ação de "manter em depósito" entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontra-se inserida no rol descrito no "caput" do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, restando demonstrada e caracterizada a prática do crime descrito na peça inicial.

Diante de tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação de crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, a condenação é medida que se impõe, uma vez que segura a provada responsabilidade penal do réu.

Passo a dosar a pena.

1) Pena - Delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003).

Na primeira fase, no que toca às circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, tenho que o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 47/48), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do mínimo legal. Por esta razão, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo de 1/30 do salário-mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Incidem no caso as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 181), bem como da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, por ter o réu confessado o delito em questão. Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada.

Torno definitiva a pena acima fixada, ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea

"c", c.c. o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal.

O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, por preencher os requisitos do artigo 44, I a III, e parágrafo 2º, do Código Penal. A prestação pecuniária consistirá no pagamento, em dinheiro, do valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, vigente na data do efetivo pagamento, o qual reverterá em benefício de entidade pública ou privada com destinação social, conforme artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, observando-se o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

Incabível a aplicação do sursis, ante a substituição acima concedida (art. 77, III, do Código Penal).

2) Pena - Delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Na primeira fase, no que toca às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59, do Código Penal, tenho que o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 47/48), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do mínimo legal. Por esta razão, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, ante a ausência de elementos que possibilitem aferir a real situação econômico-financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 181). Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, como delineado na fundamentação supra, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena pelo tráfico de drogas no regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena por estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, inciso I, e 77, "caput", ambos do Código Penal.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu MATEUS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos:

1) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com regime semiaberto para o início do cumprimento;

2) à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, por incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, com regime aberto para o início do cumprimento. Substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, nos moldes expostos na fundamentação desta sentença.

DEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade por estarem mantidas as circunstâncias que o levaram a responder ao processo até aqui solto.

DECLARO o perdimento da quantia apreendida de R\$ 180,00 (fl. 69) em favor da União, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, uma vez que inerente ao crime de tráfico praticado.

Por fim, DETERMINO a destruição das armas, munições e dos demais objetos apreendidos, por serem produtos ou estarem relacionados à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelos sentenciados, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade processual concedida nos autos em favor do réu (fl. 204).

P. R. e I.

Araçatuba, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA